

数据跨境流动安全例外条款的适用困境与中国对策

霍俊先

内容摘要：RCEP、DEPA、CPTPP 以 WTO 为范本，将安全例外条款纳入数据跨境流动规则之中，但未作出明确界定，导致该条款在适用上存在一定的模糊性。通过检视中国国内法对数据跨境流动的监管规则可以探知，以安全评估方式出境的重要数据和“达到国家网信部门规定数量的个人信息”可能会因援引安全例外条款而产生风险。回顾过往实践，WTO 争端解决专家组在“俄罗斯运输限制措施案”(DS512)中首次就援引安全例外条款作出法律解释，这足以成为数据跨境流动领域援引安全例外条款可供参考的裁判法理。中国在援引安全例外条款时，不仅要坚持 WTO 的裁判法理与“援引克制”的立场，还可利用自贸区(港)压力测试的优势，通过负面清单的形式探索“共同但有区别”的数据分类分级制度，为援引安全例外条款提供明确的国内法依据，从而降低援引该条款产生的风险。

关键词：数据跨境流动 国家安全 安全例外 基本安全利益 善意原则

DOI:10.14114/j.cnki.itrade.2025.08.006

一、问题的提出

党的二十届三中全会强调要稳步扩大制度型开放，主动对接国际高标准经贸规则，并提出要完善维护国家安全体制机制，实现高质量发展和高水平安全良性互动。在数字时代，中国致力于提升国际经贸规则水平的同时，还应密切关注数据跨境流动所带来的国家安全风险问题。

随着数字经济的快速发展，数据跨境流动已成为各国间或区域贸易协定的核心条款。但值得注意的是，数据跨境流动具有双重风险：一方面，在数字贸易环境下，以数据为载体的数字贸易本身存在危害国家安全的风险；另一方面，各国政府为避免国家安全受到威胁而对数字贸易予以规制和监管，一旦规制不当，将会违反相关国际条约下的义务，引发国际争端。根据国际法中的安全例外条款，一国在发生危机时，可采取原本不可用的措施进行自我保护，但是，若成员方不当援引安全例外条款限制数据跨境流动，不仅会造成数据本地化的结果，

抑制数字贸易的发展，而且可能被认为是对外国公司施加的不合理歧视或限制该公司贸易的发展，从而违反相关协定下的义务。

数据跨境流动领域适用安全例外条款存在一定困境，其背后既有客观原因，也有主观因素。从客观原因来看，近年来，国家安全的内涵日渐丰富，以数据安全、公共卫生安全为代表的，会对主权国家及人类发展产生威胁的非传统国家安全的重要性日益突显。加之安全例外条款规则本身的模糊性，使得基本安全利益的内涵与外延难以界定，进一步加剧了该条款适用标准的认定难度，并指向基本安全利益的范围与边界为何的问题。从主观因素来看，全球贸易格局日益向数字化转型加速发展，世界大国竞争呈现复杂化趋势，在安全例外条款尚无统一适用标准的前提下，部分国家出于数据霸权主义和单边主义，将安全例外条款武器化，随意将一般安全上升为国家安全，从而滋生了恣意适用安全例外条款的风险。目前，基于安全例外条款而限制数据跨境流动的问题尚未引发充分关注，因此，这一问

[作者信息] 霍俊先，厦门大学台湾研究院法律研究所博士研究生。电子邮箱：xmhuojunxian@163.com。作者感谢匿名审稿专家们的宝贵意见和建议，当然文责自负。

题便成为亟待研究的重要课题。

有鉴于此,本文拟以数据跨境流动之安全例外条款为研究视角,首先,以《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)等自由贸易协定^①及中国对数据跨境流动领域的规制为出发点,梳理现有规则的实践和适用安全例外条款的困境;其次,以WTO体系下已有的涉安全例外条款的争端解决实践,即全球首份成功援引安全例外条款的“俄罗斯运输限制措施案”(DS512)的裁判规则和理念为依据,分析数据跨境流动领域援引基本安全例外条款的边界和限度问题;最后,从国际贸易法规制的角度,探讨中国援引基本安全例外条款的立场与对策。

二、数据跨境流动领域安全例外条款的适用困境

RCEP、DEPA和CPTPP等自由贸易协定通过不同方式将安全例外条款不同程度地纳入协定中,但并未对安全例外条款的适用作出清晰的表述和界定,使该条款成为一项动态的国际法规则。同时,在中国现有的数据跨境流动监管体系下,以安全评估方式为出境通道所涵盖的数据类型过多,如果限制这些数据出境,可能会引发适用安全例外条款的风险。

(一)自由贸易协定涉数据跨境流动安全例外条款的适用困境

RCEP、DEPA和CPTPP将安全例外条款纳入数据跨境流动之中,主要源于《1994年关税与贸易总协定》(GATT 1994)的第21条。RCEP采取条款内置的形式,在电子商务章节中对数据跨境流动领域的基本安全例外内容作出规定。相反,DEPA和CPTPP并未在其数字贸易模块与电子商务章节中对基本安全

例外作出特定的安排,而是采取整个协定外置的安全例外条款对数据跨境流动予以规制。WTO和RCEP、DEPA、CPTPP三大自由贸易协定中安全例外条款的规则有一些差异(见表1),三大自由贸易协定中安全例外条款的适用也存在不同困境。

1. RCEP安全例外条款的适用困境

RCEP对安全例外规定的特殊性主要体现在两个方面:一是“其认为”(it considers)的表述,二是“其他缔约方不得对此提出异议”(not be disputed by other Parties)。从“it considers”的条约解释来看,其有两种解读:第一种为援引安全例外的一方享有完全的自主决定权(self-judging),涉及安全例外的争端不具有可裁判性;第二种为是否援引安全例外的主观判断由缔约方自主决定,具体原因由争端解决专家组根据客观审查来决定。但根据RCEP第12.17.3条^②的规定,RCEP数据跨境流动之安全例外条款中“其认为”的表述属于第一种,即援引安全例外条款完全是由缔约方自主决定的事项,涉及安全例外的争端不具有可裁判性。

换言之,缔约方基于“基本安全利益”而采取的限制数据跨境流动的措施属于其完全自裁决的事项,不论该措施以何种形式实施,都无须向其他缔约方说明采取措施的必要性,其他缔约方更不得对此提出异议。由于完全自裁决属性的实施空间较大,这极有可能成为缔约方泛化保护国家安全和数据主权的抓手,从主观意图上造成规则的滥用,对数字贸易的发展造成壁垒,甚至还会阻碍大型跨国企业进入一国市场开展商业活动。虽然该内置型条款没有对“安全例外”条款的内容作出具体解释,但RCEP第17.13条(b)款对此作出了具体规定,采用“其认为”的表述,将GATT 1994第21条“安全例外”项下

① 之所以选择RCEP、DEPA和CPTPP作为分析范本,是因为这三个协定与中国密切相关。RCEP是中国牵头谈判并落地生效的自由贸易协定,而DEPA和CPTPP不仅是全球高标准经贸规则的范本,也是中国正积极推动加入的协定。

② RCEP第12.17.3条规定:“任何缔约方不得就本章项下产生的任何事项诉诸第十九章(争端解决)的争端解决。作为根据第二十章第八条(一般性审议)对本协定进行的一般性审议的一部分,缔约方应当审议第十九章(争端解决)对本章的适用。审议完成后,第十九章(争端解决)应当在同意其适用于本章的缔约方之间适用。”

所规制的三种情形纳入后又新增了一种情形^①。由于适用标准较为清晰化使得援引该条款的限制性要求较高，因此成员方在 RCEP 项下援引安全例外的可能性较低。不过，不可否认的是，即使 RCEP 项下援引安全例外的可能性较低，但 RCEP“其认为”的表述将安全例外的援引决定权完全交由缔约方自主决定，一定程度上会造成安全例外条款的滥用。

根据 RCEP 第 12.17 条规定，因数据跨境流动产生的争议不适用争端解决机制，而是由各成员方协商解决或者提交至 RCEP 联合委员会解决，且成员方之间的磋商是 RCEP 联合委员会解决纠纷的前置程序。因此，成员方之间发生纠纷时，相关成员方要先采取磋商的方式，本着善意原则对所涉利益进行博弈和让步。显然，这种磋商方式并不涉及对安全例外条款的解释，而且相关成员方协商一致的结果也不能作为对该安全例外条款的规范解释，不具有可援引性。当协商无法达成一致时，可提交至 RCEP 联合委员会解决，RCEP 联合委员会虽具有规则解释的职能，但根据 RCEP 第 18.4 条的规定，该职能的行使应以各缔约方协商一致为前提，即各缔约方均对此协商结果无异议时，RCEP 联合委员会才可对该条款规则作出解释说明。但问题在于，由于缔约方之间的经济发展和开放水平的差异，较难达成协商一致的结果。

因此，以上两种方式均较难实现对数据跨境流

动安全例外条款的规范解释与恰当适用。RCEP 项下数据跨境流动适用安全例外条款的局限性在于，其完全的自主裁决空间使得一缔约方无须征得其他缔约方同意便可援引安全例外条款，且 RCEP 联合委员会无法对争议作出规范化的解释。

2. DEPA 和 CPTPP 安全例外条款的适用困境

仅就安全例外条款而言，DEPA 基本上承袭了 CPTPP 的规则内容，二者对数据跨境流动之安全例外的规制均采用外置安全例外条款的形式，具有一定的相似性。DEPA 第 15.2 条和 CPTPP 第 29.2 条均规定：任何内容均不得解释为要求一缔约方提供或允许获得其确定披露则违背其基本安全利益的任何信息，或者阻止一缔约方采取其认为对履行维护或恢复国际和平或安全义务或保护其自身基本安全利益所必需的措施。同样地，DEPA 和 CPTPP 都通过“其认为”(it considers)的表述强调缔约方在限制数据跨境流动方面的自主决定权，但这种自裁决是完全的自裁决还是一定程度的自裁决，协定并未予以说明，也无法从后续的条款中得知。与 GATT 1994 相比，DEPA 和 CPTPP 删除了 GATT 1994 第 21 条(b)款所列的三种特定事项，使安全例外条款的适用范围变得更加宽泛；DEPA 和 CPTPP 也未对“基本安全利益”的范围作出界定，一定程度上扩大了安全例外条款的适用情形。关于缔约方之间的争端解决，可以通过争端解决机制来解决，这一点与 WTO 协定保持了一致。

表 1 WTO、RCEP、DEPA 和 CPTPP 安全例外条款之比较

比较事项	WTO	RCEP	DEPA	CPTPP
是否对“基本安全利益”作出界定	作出列举	作出列举	未明确说明	未明确说明
成员方是否具有自裁决权	具有			
其他缔约方是否可提出异议	未规定	不可提出	未规定	未规定
是否可诉诸争端解决机构	可以	不可以	可以	可以

资料来源：根据相关资料整理。

① RCEP 第 17.13 条(b)款规定了四种情形，分别是：(1)与裂变和聚变物质或衍生此类物质的物质有关的行动；(2)与武器、弹药和作战物资的交易有关的行动，以及与直接或间接供应或给养军事机关的此类交易运输的其他货物和物资或提供的服务有关的行动；(3)为保护包括通讯、电力和水利基础设施在内的关键的公共基础设施(无论私有还是公有)而采取的行动；(4)在国家紧急状态，或战时，或国际关系中的其他紧急情况下采取的行动。

综上所述，与 DEPA 和 CPTPP 相比，RCEP 通过“not be disputed by other Parties”的表述表明其更加关注数据跨境流动的安全问题，将成员方的基本安全利益置于数据跨境自由流动之上，并且数据跨境流动援引安全例外所产生的争议无法通过争端解决机制解决。除此之外，这三个协定存在一定的共性，都对安全的范围进行了限缩，限定在“基本安全利益”范围内。这表明并不是任何安全都能构成免责事由，但问题在于，这三个协定都没有对“基本安全利益”的适用范围和标准进行厘定，甚至 DEPA 和 CPTPP 给予了“基本安全利益”更广泛的解释空间。因此，从三个协定的内容可以看出，安全例外条款在数据跨境领域适用时主要面临两大困境：第一，没有明确且清晰地界定“基本安全利益”的适

用范围；第二，“其认为”表述下的自裁决属性不清晰，究竟是受到专家组一定的限制，还是完全由缔约方自主决定，未得到明确界定。

(二) 中国法体系下安全例外条款的适用困境

中国对数据跨境流动的监管主要集中在“数据出境”这一环节，经过数年的实践与发展，已初步形成以三部法律为主体、以行政法规和规章为具体细则的新规制体系^①，奠定了中国数据跨境流动的监管格局，并丰富了数据出境的监管方式(见表 2)。

在这一监管体系下，数据出境的方式更加多元，流程更加便捷，为保障国家安全和数据主权提供了坚实的法律基础。在现有出境通道下，并非限制所有类型数据出境行为都能成功援引安全例外条款，个别类型的数据在援引时存在一定的风险。一方面，

表 2 中国数据跨境流动监管体系

出境监管方式	数据出境的类型	法律依据
安全评估	关键信息基础设施运营者确需向境外提供在境内收集和产生的个人信息和重要数据	《网络安全法》第 37 条 《数据安全法》第 31 条 《个人信息保护法》第 40 条
	非关键信息基础设施的数据处理者向境外提供重要数据，或者自当年 1 月 1 日起累计向境外提供 100 万人以上个人信息(不含敏感个人信息)或者 1 万人以上敏感个人信息	《数据出境安全评估办法》第 4 条 《促进和规范数据跨境流动规定》第 7 条 《网络数据安全管理条例》第 37 条
标准合同	非关键信息基础设施的数据处理者在当年累计向境外提供 10 万人以上、不满 100 万人个人信息(不含敏感个人信息)或者不满 1 万人敏感个人信息	《个人信息保护法》第 38 条 《个人信息出境标准合同办法》第 4 条 《促进和规范数据跨境流动规定》第 8 条
个人信息保护认证		
免于申报直接出境	在学术合作、国际贸易及运输等场景产生的数据，其中不包含个人信息或者重要数据	《促进和规范数据跨境流动规定》第 3 条
	将境外的数据传输至境内处理，处理过程中未引入个人信息或者重要数据	《促进和规范数据跨境流动规定》第 4 条
	为订立、履行个人作为一方当事人的合同而确需向境外提供个人信息	《促进和规范数据跨境流动规定》第 5 条 《网络数据安全管理条例》第 35 条
	因依法依规实施跨境人力资源管理而确需向境外提供员工个人信息	
	紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全而确需向境外提供个人信息	《促进和规范数据跨境流动规定》第 5 条
	关键信息基础设施运营者以外的数据处理者自当年 1 月 1 日起累计向境外提供不满 10 万人个人信息(不含敏感个人信息)	

资料来源：根据相关资料整理。

① 三部法律是指 2017 年 6 月 1 日起施行的《网络安全法》、2021 年 9 月 1 日起施行的《数据安全法》和 2021 年 11 月 1 日起施行的《个人信息保护法》。具体的行政法规和规章主要包括 2022 年 9 月 1 日起施行的《数据出境安全评估办法》、2023 年 6 月 1 日起施行的《个人信息出境标准合同办法》、2024 年 3 月 22 日起施行的《促进和规范数据跨境流动规定》，以及 2025 年 1 月 1 日起施行的《网络数据安全管理条例》。

签订标准合同、个人信息保护认证和免于申报直接出境三种方式基本涵盖了绝大多数向境外传输个人信息的情形，中国法律允许其在“适格”的情况下出境，没有附加其他限制性条件，同时也能较好地实现对此类数据的保护。因此，以上述三种方式出境通道的数据基本不存在援引基本安全例外的需要。另一方面，对于以安全评估方式出境的重要数据、达到一定量的个人信息或个人敏感信息，由于中国法律对其有境内存储的规定，如果采取限制措施，一定程度上会对国际贸易的发展造成壁垒，引发国家安全与贸易自由之间的冲突，存在援引基本安全例外条款的需求。对于这部分数据，就需要考虑中国能否顺利通过适用安全例外条款而采取限制数据出境的措施。

具体而言，以安全评估方式出境的重要数据有两类：第一类是关键信息基础设施运营者所产生的数据，第二类是非关键信息基础设施的数据处理者向境外传输重要数据或达到国家网信部门规定数量的个人信息。

关于第一类数据，需要探究“关键信息基础设施”的具体范围及其重要性。从中国国内法规制来看，《关键信息基础设施安全保护条例》通过“列举+兜底”的方法对关键信息基础设施的内涵和外延作出明确的界定^①。其在列举所涉的重要行业和领域的同时，还通过“以及其他一旦遭到破坏……”的兜底性表述将其他重要网络设施、信息系统等纳入其中，并指出一旦遭到破坏便会产生的严重后果，直接将其与国家安全挂钩。从全球范围来看，美国、欧盟、日本等国家和地区也非常重视对关键信息基础设施的保护，先后出台相关法律法规加强对关键信息基础设施的保护^②。由此可见，对关键信息基础设施进行保护，并将其提升到国家安全的战略高

度，不仅是中国的立法现状，也是世界多数国家的共识性做法。因此，中国如要禁止关键信息基础设施产生的数据向境外传输，基本可以援引安全例外条款而免责。但也存在一种极端情况，如果他国基于地缘政治因素而不认可中国界定的关键信息基础设施的范畴，便可能会引发适用争议。因此，中国有必要进一步明确数据分类分级制度，清晰化界定以安全评估方式出境的重要数据类别。

关于第二类数据，则需评判如何理解“达到国家网信部门规定数量的个人信息”。根据《促进和规范数据跨境流动规定》以及相关答记者问的内容，中国目前并没有对“达到规定数量的个人信息”适用于哪些领域和行业作出明确说明，有待通过后续的立法或者发布细则的方式予以完善。除《关键信息基础设施安全保护条例》对关键信息基础设施所界定的行业和领域外，中国还存在其他众多行业和领域，并非所有行业和领域达到规定数量的个人信息泄露都会对国家安全产生影响。因此，以 100 万人以上个人信息、1 万人以上敏感个人信息作为出境评估的标准值得商榷。如果按照现有规则操作的话，会给一些并未关涉国家安全的领域戴上个人信息出境安全评估的枷锁，进而还会引发滥用援引安全例外条款的风险。

三、数据跨境流动领域适用安全例外条款的法理借鉴

目前，国家间尚未发生因援引安全例外条款限制数据跨境流动提起的诉讼。在数字贸易视角下对基本安全利益的范畴进行界定，可参考借鉴 WTO 争端解决专家组对基本安全利益的界定和说明。截至目前，基于基本安全利益而作出的争端解决专家组报告屈指可数，虽然数据跨境流动领域适用安全例

① 《关键信息基础设施安全保护条例》第二条规定：“本条例所称关键信息基础设施，是指公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域的，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的重要网络设施、信息系统等。”

② 美国自 1996 年以来颁布《2001 年关键基础设施保护法》《加强联邦网络和关键基础设施安全》等十余部立法、总统令和计划。欧盟颁布《打击恐怖主义保护关键基础设施的通讯》《保护关键基础设施的欧洲计划》等多项规定，确保关键基础设施持续运转。日本颁布《关键基础设施信息安全措施行动计划》《重要基础设施的网络安全行动计划》等多项政策规定。

外条款并不必然遵循这些报告，但现有的 WTO 争端解决实践仍可视为宝贵的、可供参考的裁判法理。

(一)数据跨境流动领域借鉴 WTO 安全例外条款适用的正当性

数据跨境流动安全例外条款的适用借鉴 WTO 体系下的实践具有一定的合理性和可行性。

一方面，一般规则的既有适用情形可为具体规则的适用提供指引。WTO 规则在货物和服务贸易等领域发挥着重要作用，是治理数据跨境流动的重要依据。作为国际贸易领域规则建构的基础，WTO 体系下的多部协定涉及安全例外条款^①，这足以证明安全例外条款在 WTO 体系下具有基础性地位，是国际法领域极为重要的法律条款。其中，GATT 1994 第 21 条被视为各项多边贸易协定例外条款的立法渊源，同时也是对国家安全例外规定最全面、概括性最强的条文，被称为 WTO 的“君子协定”。CPTPP 第 28.12.3 条规定，对于已经纳入的有关《WTO 协定》的任何条款，争端解决专家组应当审议 WTO 有关专家组报告和上诉机构报告中的解释。如前文所述，RCEP、DEPA 和 CPTPP 对于安全例外条款的设置一定程度上遵循了 WTO 相关文件的基本用语和架构，虽然在内容表述方面有所修改，但并未违背 WTO 体系下的安全例外条款的基本范式。在当前数据跨境流动领域援引安全例外条款尚无先例的情况下，借鉴 WTO 专家组报告的解释明确数据跨境流动领域对安全例外条款的适用，具有一定的合理性。

另一方面，在大数据时代，非传统安全是对传统安全的补充，仍属于国家安全体系下的安全范畴。在网络空间、数据主权等客观形势发展变化的背景下，依据条款演化解理论，WTO 允许各国在遭受

网络攻击时实施限制措施，即 WTO 将网络安全视为国家安全。由此可见，WTO 根据新的客观形势，认可非传统的网络安全属于国家安全的范畴，国家安全从传统的外交和军事层面的安全逐渐扩大到以网络空间为代表的其他领域。作为新一代的自由贸易协定，RCEP 直接对非传统安全问题做出了回应，即安全例外条款的范围涵盖非传统安全领域^②。类似地，日本与新加坡自由贸易协定、马来西亚与澳大利亚自由贸易协定也将非传统安全纳入安全例外条款之中。我国的《国家安全法》第 2 条则从广义的角度解释国家安全的内涵^③，即中国法律语境下的总体国家安全观既涵盖传统安全，也涵盖非传统安全。这一内涵与联合国开发计划署发布的《1994 年人类发展报告》(Human Development Report 1994)中“人类安全”概念的内涵^④相吻合。因此，无论是从一般规则的指引，还是从条款本身的演化解理论来看，在数据跨境流动领域参考并适用 WTO 安全例外条款均具有一定的合理性与可行性。在探讨数据跨境流动基本安全例外条款的范围及适用问题时，借鉴专家组在 WTO 涉安全例外争端解决中的法律解释和裁判要旨，不仅能为数据跨境流动安全例外条款的解释提供指引，有效保护数据领域的国家安全利益，还能为中国对接国际高水平数字贸易规则的实践提供参考。

(二)WTO 体系下涉安全例外条款的争端解决实践

2019 年 4 月，WTO 争端解决专家组在“俄罗斯运输限制措施案”中首次就 GATT 1994 第 21 条对“安全例外”的规定作出法律解释，肯定了涉国家安全争端的可裁判性，同时也得到了中国、加拿大和

① WTO 协定项下的安全例外条款主要包括 GATT 1994 第 21 条、《服务贸易总协定》(GATS)第 14 条、《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)第 73 条，以及《与贸易有关的投资措施协议》(TRIMs)第 3 条。

② RCEP 第 17.13 条规定，该协定的任何规定不得解释为“阻止任何缔约方采取其认为对保护其基本安全利益所必需的任何行动”，其中包括“为保护包括通讯、电力和水利基础设施在内的关键的公共基础设施而采取的行动”。

③ 《国家安全法》第 2 条规定：“国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态，以及保障持续安全状态的能力。”

④ 《1994 年人类发展报告》认为，“人类安全”的概念涉及七大领域：经济、食品、健康、环境、人身、社区和政治。另外，2009 年 OECD 发布的报告《国际投资法和国家安全战略中与安全有关的条款》(Security-Related Terms in International Investment Law and in National Security Strategies)认为，恐怖主义、流行病、自然灾害、组织犯罪、网络威胁、人口和毒品贩运、移民和气候变化等均对国家安全构成威胁。

欧盟等主要 WTO 成员的支持。此案作为成功援引安全例外条款的第一案，受到国际社会的高度关注。虽已过数年，但专家组报告仍具有巨大的参考价值，应当成为深入研究安全例外条款在数据跨境流动领域如何适用的逻辑起点。在该案中，双方的争议焦点主要在于 WTO 专家组对安全例外的判定是否享有管辖权、如何界定“基本安全利益”，以及 GATT 1994 第 21 条(b)款属于主观判断条款还是客观裁决条款。

首先，针对管辖权问题，专家组认为 WTO 争端解决机构作为国际准司法机构，对安全例外条款具有管辖权，成员方不享有完全的自主管辖权。根据 WTO《关于争端解决规则与程序的谅解》(DSU)的有关规定，GATT 1994 适用争端解决机制，且第 21 条不属于 DSU 附件 2 所规定的不适用争端解决机制的条款。“其认为”的措辞作为 GATT 1994 第 21 条的部分表述而存在，必然要受到 DSU 规定的争端解决机构的管辖。

其次，针对“基本安全利益”的范围界定，专家组认为应仅限于与国家根本职能密切相关的利益。对于何为“与国家根本职能密切相关的利益”，专家组给出了列举，例如，维护国家领土主权以及人民免受外来势力的干涉与威胁，维护国家法治，保障社会公共秩序。可以说，衡量基本安全利益的重点在于对国家安全的危害程度达到上述相当程度的标准。

最后，专家组还区分了安全例外条款的自裁决属性。WTO 专家组通过多方论证并翻阅谈判历史，对 GATT 1994 第 21 条(b)款中的“战争或国际关系中的其他紧急状态期间”作出了法律解释和说明，即国际关系紧急状态必须涉及国防、军事或维护法律和公共秩序利益，而不涵盖国与国之间的一般性的政治或经济分歧。因此，对于被告方是否可在采取措施后援引安全例外条款中的“国际关系紧急状态”免责，由专家组根据所涉案件的具体情况作出客观判断，而不是依据被告方的主观判断，被告方的主观判断仅及于其为保护“基本安全利益”而采取必要措施的自主决定权。当然，客观标准判断同样适用于 GATT 1994 第 21 条(b)款中的另外两种情形。

专家组做出的裁判结论不仅是条约解释的结果，更是领悟和思考各成员方倾向的结果，专家组与成员方之间的关系可以理解为“微妙与非正式的共生关系”。因此，这一裁判结论具有一定的借鉴性，可以作为数据跨境流动之安全例外条款适用的基础和起点。

(三)对裁判法理的借鉴与反思

对于数字贸易规则领域而言，该案的三个裁判要点具有明显且重要的参考价值。

第一，谨慎对待安全例外条款的自裁决属性。WTO 专家组承认安全例外条款的自裁决属性，但并不是缔约方完全自主的裁判权。基于数字贸易领域暂无涉及安全例外条款的纠纷，未来的适用形势并不明确，可能参照专家组报告的裁判法理，也可能在专家组报告的基础上进行优化。唯一明确的是，中国应当重新审视安全例外条款的自裁决属性，根据实践情势，适时把握好半自主裁判权的度。

第二，明确“基本安全利益”的内涵。基本安全利益是一个范围相对狭窄的概念，虽然 WTO 专家组作出了其不等同于一般安全利益的解释与澄清，但并未对“国际关系中的其他紧急情况”作出清晰化的界定，仅揭示了“国际关系中的其他紧急情况”在程度上至少要达到与“战争”结果相类似的程度。在美国针对钢铁和铝产业发起的 232 调查案中，其声称援引安全例外条款是为了维护国家安全，实则是借国家安全之名谋取经济利益，专家组认为全球钢铝过剩影响经济利益，但未对国家安全造成危害，更不能上升到“国际关系中的其他紧急情况”的高度。因此，在数据跨境流动领域，可以考虑将成员方的共同意图作为判断是否构成“基本安全利益”的依据，这样不仅可以避免成员方滥用自主裁判权，也可以为非传统安全领域的适用提供指引。就共同意图的理解而言，并非指所有成员方对“基本安全利益”的界定要完全一致，而是要反映多数国家对“基本安全利益”的理解。

第三，关于善意原则在解释中的运用。善意原则虽然是一项习惯国际法原则，但在《维也纳条约法公约》中得到体现，是条约解释必须遵守的核心原则，其法理意涵便在于平衡与协调相关利益。例

如, WTO 专家组在“沙特阿拉伯知识产权案”(DS567)中强调, 善意原则具有避免安全例外条款滥用的功能, 不得利用该原则规避 GATT 1994 第 21 条项下的义务。作为打破安全自决权功能局限性的工具, 对安全例外条款的解释应当受到善意原则的审查, 需要成员方恪守善意义务, 酌情谨慎作出判断, 且采取限制数据跨境流动措施的成员方负有“自证善意”的义务。因此, 数据跨境流动领域援引安全例外条款的核心在于遵守善意原则, 这应贯穿于条约解释和运用的全过程。根据发生争端时的实际环境和特定情况, 依善意原则的内涵对所要保护的利益作出解释说明, 并证明所要保护的利益能达到“与国家根本职能密切相关的利益”相当的程度, 所采取的措施应当是对贸易限制最小的措施。

四、中国对策: 坚持 WTO 实践理念与自贸区(港)制度探索并行

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中, 明确提出“加快建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范”。对数据跨境流动安全例外规则进行研究的意义便在于使数据出境的通道更加规范和畅通, 确保在必要时所采取的数据本地化措施符合安全例外的制度规范。中国要对接国际高标准经贸规则, 不仅要坚持 WTO 体系下的价值立场, 还应当完善国内法对数据跨境流动监管的规制, 从而化解数据跨境流动领域援引安全例外条款的困境。

(一) 价值立场: 能动和克制之间保持“援引克制”

首先应当明确的是, 中国不支持安全例外条款的泛化适用与滥用, 但也不反对安全例外条款在合法范围内的善意适用。对此, 中国应当本着“援引克制”的理念严格援引安全例外条款。所谓“援引克制”, 是指一成员方应当限制自身对安全例外条款的适用与解释, 通过其他恰当方式处理这一棘手问题, 约束安全例外条款的滥用。如确需援引, 则应在合法合理的框架下适用安全例外条款, 采取相应的贸易限制措施。

一方面, 从 GATT 1994 的历史谈判文献中可以探知, 绝大多数国家表示对“基本安全利益”的理解难以把握且对援引该条款呈善意克制的态度, 同时也对该条款的援引充满担忧。中国于 2019 年 5 月 13 日正式向 WTO 提交了《中国关于世贸组织改革的建议文件》, 该文件在“解决危及世贸组织生存的关键和紧迫性议题”中提到要“加严对滥用国家安全例外的措施的纪律”, 不仅建议成员方“秉承善意和克制原则援引安全例外条款”, 还建议 WTO 加强对援引国家安全例外的做法的通报纪律, 并开展多边审议。此外, WTO 成员方在对待安全例外条款做出的权威解释或修正方面存在严重分歧, 例如, 美国反对 WTO 争端解决机构审理涉及安全例外的争端, 欧盟则赞成对安全例外条款做出的限缩性解释。这足以表明安全例外条款的易滥用性, 多数国家对此存在担忧。因此, 建议中国秉承 WTO 体系下多数成员方所坚持的“援引克制”的态度, 首选协商的方式解决所面临的国家安全风险问题。

另一方面, 中国也要做好适用该条款的准备工作。作为“援引克制”的退路, 在无法通过外交途径解决涉国家安全风险问题时, 可基于安全例外条款采取贸易限制措施。因此, 需要做好援引安全例外条款的准备工作, 遵循 WTO 争端解决实践中主客统一立场的裁判法理。裁判法理以其独特的柔韧性, 可以灵活适应科技社会出现的新问题, 裁决不仅是对安全例外条款模糊性及如何适用的最好法律解释, 还可为嗣后的争端解决提供有效的指引。首先, 在采取贸易限制措施援引安全例外条款时, 中国应本着善意原则对涉国家安全的风险进行充分调查与评估, 以确保所采取的措施具有正当性与必要性, 未超出保护必要的国家安全的限度。其次, 还需把握实施制裁的力度, 定期开展对国家安全风险的评估, 根据危及国家安全的程度, 相应地提升、降低或取消贸易限制措施, 以免引发纠纷。最后, 如果他国针对中国采取的贸易限制措施提起诉讼, 要依据 WTO 争端解决实践中主客统一立场的裁判法理进行抗辩。作为被诉方, 中国需保存好采取措施的有关证据, 承担相应的举证责任, 以供争端解决机构进

行客观审查。一国援引安全例外条款实际上是对国际义务的违反,根据联合国国际法委员会的观点,违反国际义务的一方需要为其行为提供正当理由,承担相应的举证责任。例如,在“CMS 公司诉阿根廷案”中,仲裁庭要求援引安全例外条款的阿根廷一方承担相关的举证责任。此外,中国还需考虑对“基本安全利益”作出合理的解释,即从多数国家的共同意图出发,将所遭受的危险与国家安全问题挂钩,确保危险与国家安全之间有较强的关联性。

(二)安全进路:自贸区(港)探索“共同但有区别”的重要数据目录

重要数据范围界定过宽,容易对数据出境造成限制,因此数据分类的精准化和界定标准的明晰化,是中国稳健援引安全例外条款的重要前提。在中国当前的实践中,自贸区(港)制度探索走在改革前列,主动承担对接与试点的任务,成为经贸规则与国际高标准对接的高地,并逐步引领国内规则发展导向。自贸区(港)是中央政策先行与地方授权立法相结合的法治试验田,具有先行先试和压力测试的职能。因此,中国可在自贸区(港)进行负面清单制度探索,借助负面清单制度仅保留少量数据进行监管的特点,进一步细化不同领域、不同场景下的数据分类和分级,扩大数据出境的场景与规模,放宽对负面清单外数据跨境流动的限制程度,让更多无需以安全评估方式出境的数据能够更顺畅、更自由地出境,从而降低援引安全例外条款的风险。

1. 基本原则

原则上来讲,出台并细化重要数据目录属于“国家事权”,不过,2024年3月公布施行的《促进和规范数据跨境流动规定》第6条规定,自贸区可在国家数据分类分级保护制度框架下,自行制定区内需要纳入数据出境安全评估的数据清单(负面清单),对于负面清单外的数据则可免于申报直接出境,且只需把负面清单报国家网信部门、国家数据管理部门备案即可。基于此,自贸区(港)应以坚守国家安全为底线,以坚持动态调整为要求,按照包容审慎、促进发展、保障权益的原则,探索“共同但有区别”的重要数据目录。“共同”是指以国家相

关法律法规对重要数据的范围界定为基础,这是探索重要数据目录的根本所在,可以有效避免各地区对同类重要数据界定不一的情形;“有区别”是指各自自贸区(港)应当根据国家政策的引导,结合区域内的产业结构、企业主体、技术合作对象、主要贸易地、风险是否可控等因素动态调整重要数据目录的负面清单,这是探索重要数据目录的基本方法。

2. 工作机制

为更好地保障数据出境的便利化,建议建立事前事后全链条的工作机制。第一,可由自贸港(区)所在行政区的发展和改革委员会、数据局等管理部门建立数据出境负面清单管理体系,并对相关事项进行统筹协调。第二,建立相应的数据出境联席会议制度,负责负面清单制度中数据类别的动态更新与编制操作指引等工作。第三,在有关地区开展数据跨境传输试点工作,在确保安全的前提下有序放宽或取消数据出境限制举措,充分释放数据活力。第四,建立相应的风险防范和监督管理机制,由相关监管部门对负面清单数据的采集和出境进行严格审查,通过定期或抽检的方式,对负面清单的落实情况 and 数据处理者进行监督,并对违规操作者进行法律追责。

3. 操作方法

具体而言,在对某一行业或领域的重要数据以负面清单的形式作出界定后,各自自贸区(港)可本着“出境自由,精准援引安全例外”的理念开展压力测试。第一步,针对已有的数据分类分级、数据安全保护等规则制度进行调整,拟定相关的监管体系和规则标准,为开展压力测试提供安全保障。第二步,根据以安全评估为出境方式的重要数据的实际情况,先拟定一个峰值,低于或等于该峰值数量的数据或个人信息可通过其他便捷方式出境。然后在新一轮测试的基础上,可逐渐增加可出境数据或个人信息数量,在压力测试中不断扩大超过规定数量的个人信息的出境规模。这一步骤可多次循环反复操作,直到接近威胁国家安全的红线。第三步,在数轮的测试中形成较为完备的重要数据目录。

需要注意的是,在测试的过程中需把控好对风

险的监测、预防和应对。同理，其他领域和行业的重要数据也可依照此种办法进行压力测试，最终形成可复制、可推广的数据分类分级和数据出境监管制度。例如，2024 年 5 月，天津自贸区管委会与天津市商务局等部门出台《中国(天津)自由贸易试验区数据出境管理清单(负面清单)(2024 年版)》。这是中国首份自贸区(港)数据出境负面清单，在数据分类分级的基础上，将各行业或领域内出境的数据分为 13 个大类 46 个子类，根据子类数据的基本特征作出详细描述，并给出具体的示例。该制度的出台细化了重要数据目录，有助于数据依法有序且高效出境，减轻企业或机构数据出境的合规压力，降低了因限制数据出境而适用安全例外条款的风险。类似地，上海市于 2025 年 2 月出台《中国(上海)自由贸易试验区及临港新片区数据出境管理清单(负面清单)(2024 版)》，对需要通过安全评估方式出境的重要数据作出了详细列举。

五、结 论

在当前尚未对安全例外条款的内涵与边界作出统一规定的情况下，中国应当在坚持数据跨境流动自由的基础上，本着善意的国际法原则援引安全例外条款，合理界定“基本安全利益”，充分发挥安全例外条款平衡贸易自由与国家安全的价值，而非利用该条款规避条约项下的义务，随意将政治主导下的贸易利益上升到国家安全的高度。这不仅是中国，也应当成为世界各国所秉承的立场，更是未来 WTO 机制改革所要实现的效果。此外，各国所面临的国家安全问题已经超越传统安全的范畴，非传统安全领域的发展改变了国家安全的形势。未来，在 WTO 框架内中国应当与立场相似、价值观相近的国家或地区携手合作，在全球层面推动统一的数字贸易规则，推动安全例外条款的适用范围清晰化发展，尤其要明确该条款涵盖哪些特定情形下的非传统安全领域，而非摒弃安全例外条款的“例外”本质，随意扩大至全部领域，进而促进更多国家在适用安全例外条款方面达成共识。可以说，在国家安全内涵和范围日益丰富的新形势下，如何在多边体制下实现对安全例外条

款的规范构建与有效解释，实现各国间国家安全与贸易自由的良性互动，仍是值得继续研究的领域。

参考文献

[1] 陈卫东. WTO 例外条款解读[M]. 北京: 对外经济贸易大学出版社, 2002.

[2] 陈喆. WTO 安全例外条款的适用问题研究[M]. 北京: 法律出版社, 2023.

[3] 成小爱. 总体国家安全观下数据出境安全评估的制度优化[J]. 兰州学刊, 2024(11): 95-112.

[4] 杜玉琼, 罗新雨. RCEP 数据跨境流动规则例外条款的适用及中国应对[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2023, 50(5): 75-83.

[5] 古祖雪. 现代国际法的多样化、碎片化与有序化[J]. 法学研究, 2007(1): 135-147.

[6] 洪延青. 中国数据出境安全管理制度“再平衡”——基于国家间数据竞争战略的视角[J]. 中国法律评论, 2024(3): 201-212.

[7] 洪治纲, 霍俊先. RCEP 对数据跨境流动的规制及其重要影响[J]. 西南金融, 2022(4): 83-94.

[8] 胡加祥. WTO 法律解释权的错配与重置[J]. 法学, 2021(10): 181-192.

[9] 霍俊先. DEPA 数据跨境流动: 规制差异与中国因应[J]. 国际经贸探索, 2024, 40(3): 107-120.

[10] 季烨, 霍俊先. 契合 RCEP 理念的数据保护法域外效力规则的建构[J]. 国际贸易, 2023(12): 84-92.

[11] 李宏兵, 柴范, 翟瑞瑞. 跨境数据流动的全球态势、规则比较与中国策略[J]. 国际经济合作, 2023(6): 30-41.

[12] 廖丽, 武子微. 国家安全例外条款在数据跨境流动中的适用研究[J]. 国际贸易, 2024(8): 87-96.

[13] 马光. FTA 数据跨境流动规制的三种例外选择适用[J]. 政法论坛, 2021, 39(5): 14-24.

[14] 彭德雷. 数字贸易的“风险二重性”与规制合作[J]. 比较法研究, 2019(1): 172-186.

[15] 彭阳. 国际经济治理中的国家安全泛化: 法理剖析与中国应对[J]. 国际法研究, 2022(5): 87-107.

[16] 徐莉. 安全例外条款之善意原则的适用——基于数字贸易规制视角[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2023, 51(5): 99-109.

[17] 余劲松. 国际投资条约仲裁中投资者与东道国权益保护平衡问题研究[J]. 中国法学, 2011(2): 132-143.

[18] 周念利, 于美月, 孙勤娜. 对标“贸易面向型”国际数

- 据规则提升自贸区(港)数据治理水平[J]. 国际商务研究, 2025, 46(1): 73-85.
- [19] CRAWFORD J. The International Law Commission's articles on state responsibility: introduction, text and commentaries [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- [20] HOWSE R. The World Trade Organization 20 Years on: global governance by judiciary[J]. European journal of international law, 2016, 27(1): 9-77.
- [21] ICSID. CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/01/8) [EB/OL]. (2007-09-25) [2025-05-04]. <https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/01/8>.
- [22] OECD. Security-related terms in international investment law and in national security strategies [R/OL]. (2009-01-01) [2025-05-04]. https://www.oecd.org/en/publications/security-related-terms-in-international-investment-law-and-in-national-security-strategies_0e7c951e-en.html.
- [23] SCHLOEMANN H L, OHLHOFF S. "Constitutionalization" and dispute settlement in the WTO: national security as an issue of competence[J]. American journal of international law, 1999, 93(2): 424-451.
- [24] United Nations Development Programme. Human development report 1994 [R/OL]. Oxford: Oxford University Press, 1994 [2025-05-04]. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994encompletenostats.pdf>.
- [25] WTO. DS512: Russia — Measures concerning traffic in transit [EB/OL]. (2019-04-26) [2025-05-04]. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds512_e.htm.
- [26] WTO. DS567: Saudi Arabia — Measures concerning the protection of intellectual property rights [EB/OL]. (2022-04-25) [2025-05-04]. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds567_e.htm.
- [27] WTO. DS564: United States — Certain measures on steel and aluminium products [EB/OL]. (2023-01-26) [2025-05-04]. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds564_e.htm.

Dilemma in the Application of Security Exceptions Clause for Cross-border Data Flow and China's Countermeasures

HUO Junxian
(Xiamen University)

Abstract: The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), the Digital Economy Partnership Agreement (DEPA), and the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) take the WTO as a model and incorporate the security exceptions clause into the rules of cross-border data flow, but do not make clear definitions, resulting in a certain ambiguity in the application of this clause. By examining the regulatory rules of China's domestic laws on cross-border data flow, it can be found that important data and "personal information reaching the specified amount by the national cyberspace administration department" that are exported through security assessment may be subject to the risk of invoking the security exceptions clause. Reviewing past practices, the WTO dispute settlement panel made a legal interpretation of the invocation of the security exceptions clause for the first time in the DS512 case; Russia—Measures Concerning Traffic in Transit, which is sufficient to become a reference for the invocation of the security exceptions clause in the field of cross-border data flows. When invoking the security exceptions clause, China should not only adhere to the WTO's judicial principle and the position of "invocation restraint" but also take advantage of the stress test in the free trade zones (ports) and explore a "common but differentiated" data classification and grading system in the form of a negative list, so as to provide a clear domestic legal basis for invoking the security exceptions clause, thereby reducing the risks of invoking the clause.

Keywords: cross-border data flow; national security; security exceptions; essential security interests; principle of good faith

JEL Classification: F02, F13, K33, O24

(责任编辑: 汪沁 王勇娟)